

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제1절 상소의 의의>

I. 개념

1. 상소의 정의

- 상소란 미확정의 재판에 대하여 하급법원의 판단에 불복하여 상급법원에 그 당부의 조사를 신청함으로써 재판의 취소 또는 변경을 구하는 불복신청 방법을 말한다. 이는 재판의 정확성을 기하고 당사자의 권익을 보호하기 위한 제도적 장치로서, 국가 형벌권이나 사법권의 적정한 행사를 도모하며 오판으로 인한 당사자의 불이익을 구제하는 데 그 일차적인 목적이 있다.

2. 상소의 특징

- 상소는 다음과 같은 세 가지 핵심적 요소를 갖추어야 한다. 첫째, 미확정의 재판을 대상으로 한다. 이미 확정되어 기판력이 발생한 재판에 대해서는 일반적인 상소방법으로 다룰 수 없으며, 재심이나 특별항고와 같은 비상구제수단만이 허용된다. 둘째, 상급법원에 대한 신청이어야 한다. 하급법원의 판단을 상급법원이 다시 검토하게 함으로써 수직적인 심사 구조를 형성한다. 셋째, 재판의 취소 또는 변경을 목적으로 한다. 하급심 재판의 오류를 바로잡아 자신에게 유리한 재판을 얻어내고자 하는 공격적·방어적 성격을 띤다.

3. 상소권의 발생과 소멸

- 상소권은 재판의 선고 또는 고지와 동시에 발생한다. 당사자가 재판의 내용에 만족하지 못할 경우 법이 정한 상소기간 내에 상소장을 제출함으로써 권리를 행사할 수 있다. 상소권은 상소기간의 도과, 상소권의 포기, 상소의 취하 등에 의하여 소멸한다. 특히, 기간 내에 상소를 제기하지 않으면 해당 재판은 확정되어 더 이상 일반적인 상소로는 다룰 수 없게 된다.

4. 상소의 이익

- 상소가 유효하기 위해서는 상소를 제기하는 당사자에게 상소의 이익이 있어야 한다. 우리 판례는 원칙적으로 형식적 불복설에 입각하여 판단한다. 즉, 하급심 판결의 주문과 당사자의 신청(청구취지)을 비교하여 당사자가 신청한 것보다 불리한 판결이 내려졌을 때 상소의 이익이 인정된다. 다만, 예외적으로 판결 주문상으로는 승소하였더라도 판결 이유 중에서 당사자에게 실질적인 불이익이 발생하는 특수한 경우에는 실질적 불복설의 관점에서 이익을 인정하기도 한다.

5. 상소의 종류

- 상소는 불복의 대상이 되는 재판의 종류에 따라 구분된다. 제1심 종국판결에 대한 상소는 항소라 하며, 제2심 종국판결에 대한 상소는 상고라 한다. 한편, 결정이나 명령과 같은 부수적 재판에 대한 상소는 항고라고 부른다. 항고는 다시 그 성격에 따라 일반항고, 즉시항고, 재항고 등으로 세분화되어 각각의 불복 요건과 절차적 기한을 달리한다.

II. 구별

1. 재심과의 구별

- 상소와 재심은 재판의 오류를 시정한다는 점에서 유사하나, 그 대상과 시점에서 근본적인 차이가 있다. 상소는 미확정 재판을 대상으로 하여 판결의 확정을 차단하는 정지적 효과가 있는 반면, 재심은 이미 확정된 재판의 효력을 사후적으로 배제하기 위한 비상구제수단이다. 또한, 상소는 반드시 상급법원에 제기하여 심판을 구하는 수직적 절차이지만, 재심은 원칙적으로 재판을 내린 당해 법원이 다시 심리하는 수평적 재확인 절차의 성격이 강하다.

2. 이의신청과의 구별

- 이의신청은 넓은 의미의 불복방법에 포함되나, 상소와는 달리 반드시 상급법원에 신청하는 것이 아니다. 예컨대 지급명령에 대한 이의신청이나 소송비용액 확정결정에 대한 이의신청은 해당 처분을 내린 법원에 직접 제출한다. 상소는 심급 구조를 이용한 계층적 불복인 반면, 이의신청은 동일 심급 내에서의 재검토나 절차적 위법의 시정을 요구하는 방법이라는 점에서 구별된다.

3. 특별항고와의 구별

- 특별항고는 불복할 수 없는 결정이나 명령에 대하여 재판에 영향을 미친 헌법 위반이나 법률 위반이 있는 경우에 한하여 대법원에 제기하는 특수한 불복방법이다. 일반 상소가 사실관계의 오류나 일반 법령 적용의 부적절함을 포괄적으로 다루는 것과 달리, 특별항고는 오로지 법령 해석의 통일과 헌법 수호를 위해 지극히 제한적인 사유로만 인정된다는 점이 특징이다.

4. 중간판결에 대한 불복과의 구별

- 중간판결은 소송 진행 중 개별적인 쟁점에 대해 미리 판단을 내리는 것이지만, 이에 대해서는 독립하여 상소할 수 없다. 민사소송법은 소송의 지연을 방지하고 심판의 집중을 도모하기 위하여 중간판결에 대한 불복은 그 후에 나오는 종국판결에 대한 상소와 함께 하도록 규정하고 있다. 즉, 상소는 원칙적으로 절차를 완전히 마무리 짓는 종국판결을 대상으로 한다는 점에서 중간적 판단에 대한 단순한 이의와 차별화된다.

5. 항고와 상고의 구별

- 항고와 상고는 모두 상급법원에 대한 불복이지만 대상 재판이 다르다. 항고는 결정이나 명령에 대한 불복방법이며, 상고는 제2심 판결에 대한 불복 방법이다. 항고는 상대적으로 경미하거나 절차적인 사항을 다루는 경우가 많아 서면 심리 위주로 신속하게 진행되나, 상고는 법률심으로서 원심판결의 법령 위반 여부를 엄격히 심사하며 대법원이 그 심판을 담당한다는 점에서 사법 체계상 중대성이 다르다.

III. 결론

- 상소 제도는 사법 재판의 정확성을 보장하고 법관의 오류나 편견으로부터 국민의 권리를 보호하는 필수적인 소송법적 장치이다. 미확정 재판을 상급법원에 이심시켜 다시 판단을 받게 함으로써 사법에 대한 국민의 신뢰를 제고하고 법치주의의 실질적인 구현을 가능케 한다. 상소의 개념을 명확히 이해하고 다른 불복수단과의 한계를 구분하는 것은 적절한 재판을 받을 권리를 실현하는 기초가 된다. 따라서 당사자는 상소의 이익과 대상, 기간을 면밀히 검토하여 정당한 권리 구제를 도모하여야 하며, 법원은 상소의 적법성을 엄격히 판단하여 남상으로 인한 소송 지연을 막는 동시에 억울한 오판이 방지되지 않도록 그 운영에 만전을 기하여야 한다. 결국 상소심 절차는 하급심의 독립성을 존중하면서도 상급심의 감독 기능을 조화시켜 공정한 판결을 도출해 내는 사법 시스템의 핵심 보루라 할 것이다.